

1503471-82.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... de que tais drogas se destinavam ao tráfico. O crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 comporta diversas formas de cometimento, não sendo imprescindível, para sua configuração, que o autor pretendesse, pessoalmente, vender os entorpecentes. Nesse contexto, de rigor a condenação do réu pelo delito de tráfico, que restou seguramente comprovado. No caso concreto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

[https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/](https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/Ea_5FZ7ApuZFtF7_qgWzLqYBgPcuLW2LXhPvNk8lwDGeeg?e=IfexFH)

Ea_5FZ7ApuZFtF7_qgWzLqYBgPcuLW2LXhPvNk8lwDGeeg?e=IfexFH

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1503471-82.2021.8.26.0302 - Controle 2021/001223

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2265443/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 20538987 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 5521/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2265443 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 5521/21/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA

Em 16 de março de 2022, no horário designado, foi realizada, excepcionalmente, devido à Pandemia do COVID-19, audiência virtual, nos termos dos comunicados CG Nº 284/2020 e 317/2020, bem como do comunicado CSM 2557/2020, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado GUILHERME AUGUSTO DA SILVA; o acusado referido; e as testemunhas Rodrigo Martins Garcia, Marcos Adriano Pontalti e Jesse Gomes de Menezes, que prestaram seus depoimentos. O Ministério Público informou que desiste da oitiva de Rodrigo, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Ao Final, o Ministério Público assim se manifestou: "MMª Juíza: Adito a denúncia de p. 02/03, para constar que, desde data incerta até o dia 28 de setembro de 2021, nesta cidade e comarca de Jaú, GUILHERME AUGUSTO DA SILVA, já qualificado nos autos, associou-se a indivíduo não identificado, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto porque, formalmente ouvido, o denunciado admitiu que estava "guardando" a droga apreendida, que pertencia a um terceiro. Ele explicou que tinha

uma dívida com este indivíduo não identificado e admitiu que essa parceria estava ocorrendo para quitação de uma dívida no importe de R\$1800,00 há pelo menos 15 dias. A associação entre eles, portanto, era estável e tendia a permanecer enquanto vantajosa para ambos. O denunciado informou que quitava aproximadamente R\$200,00 por semana para guardar a droga e optou por essa atividade ilícita apesar de ter renda oriunda de atividade lícita remunerada. Posto isto, adito a denúncia, para constar que GUILHERME AUGUSTO DA SILVA fica também denunciado como incurso no art. 35, da Lei nº 11.343/06, observado o concurso material com as infrações que já haviam sido objeto de imputação, ratificando a inicial em seus demais termos. O Ministério Público não tem outras provas a produzir além daquelas já existentes nos autos e registra que o presente aditamento está baseado unicamente no interrogatório do próprio acusado. Consigna, por isso, entender dispensável novo interrogatório. Por fim, retifica o erro material constante da denúncia, para constar que a quantidade de droga que denunciado trazia consigo, transportava e mantinha em depósito era de "37,8 kg de maconha" e não "27,8kg", como constou." Em seguida, se manifestou a Dra. Defensora: " MM Juíza, a Defesa se opõe ao aditamento da denúncia, uma vez que o aditamento se faz exclusivamente com base no interrogatório do réu e ao ser questionado, o réu expressamente negou que houvesse qualquer parceria ou associação. Relatou que estava guardando a droga. Houve, então, uma confissão que estava mantendo em depósito e em momento algum o réu afirmou que estivesse associado ao tráfico. Assim, a Defesa se opõe ao aditamento." Seguiu-se deliberação da MM Juíza: "VISTOS. Considerando que os argumentos apresentados pela Defensora dizem respeito ao mérito, recebo o aditamento da denúncia, uma vez que preenchido os requisitos legais. Anote-se." As Partes informaram que não há outras provas a serem produzidas e dispensam novo interrogatório do réu. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. GUILHERME AUGUSTO DA SILVA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2022. (p. 222) e o réu foi citado. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas e interrogado o réu. Após as oitivas, o representante do Ministério Público apresentou aditamento à denúncia, a fim de que o réu seja incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, do qual foram cientificados o acusado e sua Defensora. Recebido o aditamento, as partes informaram que não desejam a produção de novas provas. Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a absolvição pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo de exame químico-toxicológico. A autoria do crime de tráfico é certa. Em juízo, o réu admitiu a guarda do entorpecente e alegou que o estava fazendo há duas semanas para quitação de dívida com traficante. A confissão do acusado foi corroborada pelas provas produzidas. Os policiais militares contaram ter recebido informações de que um indivíduo chamado Guilherme, cujas características e veículo foram indicados, praticava o tráfico em um determinado horário. Realizaram patrulhamento e avistaram o acusado conduzindo o automóvel mencionado. Ele tentou empreender fuga e dispensou um invólucro contendo maconha, mas foi abordado. O réu indicou uma residência na qual havia grande quantidade de maconha, além de cocaína e apetrechos para fracionamento dos entorpecentes. Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime de tráfico imputado ao acusado. Além de ter dispensado maconha ao tentar se evadir da abordagem policial, na residência do réu foi encontrada vultosa quantidade de maconha (quase 40kg), além de cocaína e de apetrechos para fracionamento do entorpecente. Não há dúvida, tanto pela quantidade quanto pelo relato do próprio acusado, de que tais drogas se destinavam ao tráfico. O crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 comporta diversas formas de cometimento, não sendo imprescindível, para sua configuração, que o autor pretendesse, pessoalmente, vender os entorpecentes. Nesse contexto, de rigor a

condenação do réu pelo delito de tráfico, que restou seguramente comprovado. No caso concreto, porém, a despeito dos indícios da associação, não há provas suficientes para o seguro reconhecimento deste delito, já que o réu mencionou a guarda das drogas há tempo relativamente pequeno e não foram colhidos outros elementos seguros a demonstrar o vínculo associativo. Assim, de rigor a parcial procedência da ação para o fim de condenar o réu apenas pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar a pena. Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a expressiva quantidade de maconha apreendida. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência (pg. 244) e a prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, tendo em vista o disposto no art. 67, CP e o fato de que a reincidência é específica, aumento a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão e 832 dias-multa. Inaplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, considerando a reincidência do acusado. Pela mesma razão, e tendo em vista, ainda, o quantum da pena, ela deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada

em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Para ilustrar tal afirmativa, pode-se tomar por base o seguinte exemplo: um indivíduo condenado, por um crime qualquer, a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão – pena que importaria a fixação do regime inicial fechado (art. 33, § 2º, do Código Penal) – e que tenha ficado preso preventivamente por 09 (nove) meses, terá a sua pena reduzida para 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, podendo iniciar a sua pena no regime semiaberto após ter cumprido 09 (nove) meses no regime fechado (prisão preventiva). Por outro lado, se este mesmo indivíduo, condenado a 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por um crime qualquer, não tivesse ficado preso provisoriamente, estaria ele obrigado a iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado e só poderia progredir para o regime semiaberto após ter cumprido 1/6 (um sexto) da sua punição, ou seja, seria exigido que ele cumprisse 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de regime fechado para que, comprovado seu bom comportamento carcerário, ele pudesse fazer jus ao regime prisional menos restritivo. A situação é ainda mais desproporcional no caso de condenações por crimes hediondos, onde a fração de pena cumprida para progressão de regime é maior do que a prevista na Lei de Execuções Penais, variando de 2/5 (dois quintos) a 3/5 (três quintos). Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu GUILHERME AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 832 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, mas para absolvê-lo da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP. O réu não poderá apelar em liberdade. Preso no curso do processo, com maior razão deverá permanecer custodiado, a fim de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do veículo, pois utilizado na prática delitiva,

e demais objetos apreendidos. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida às partes para ciência. O Ministério Público informou que não deseja recorrer. O Réu e a Defensora informaram que desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185).
Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: GUILHERME AUGUSTO DA SILVA

RG: 41443371, RJI: 214068523-32

Data De Nascimento: 11/03/1994

Filiação: pai VALDEMAR DA SILVA, mãe ROSALINA VALIN DE OLIVEIRA

Residência: OLÍVIA ACAYABA, 68, VILA PADRE NOSSO, OLÍVIA ACAYABA - CEP 17202-420, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.